



网络社会治理的法治模式*

徐汉明 张新平

摘要：法治是国家治理的基本形式，法治模式是网络社会治理的必由之路。网络社会的本质，是公民、法人及其他组织等主体之间的各种关系基于互联网技术产生聚合而形成的新的社会关系格局和结构形态，是现实经济、政治、文化、社会、生态领域各种关系的单一或综合反映、延伸和表达。网络社会治理的法治模式，是指运用法治思维和法治方式，将网络社会治理要素、治理结构、治理程序、治理功能纳入法治范围及运行轨道的治理理论、制度与实践。梳理回顾我国网络社会治理法治建设的曲折发展历程，总结网络社会治理法治建设有益经验，反思现存立法、执法和司法困境，可以构建出规范完备、实施高效、监督严密、保障有力的中国特色网络社会治理法治制度体系，保障运用法治思维和法治方式治网、办网、用网、护网，实现网络社会在法治轨道上健康有序运行发展，推进网络社会治理体系和治理能力现代化。

关键词：网络社会 法治模式 网络治理 法治 治理

作者徐汉明，中南财经政法大学教授（武汉 430073）；张新平，中南财经政法大学博士研究生（武汉 430073）。

人类历经每一次重大技术革命都是其肢体、心智的延伸和体力、脑力的增强。^①从社会发展史看，历经从采食捕猎走向栽种畜养增强生存能力的农业革命，从个体工场手工生产走向大规模工厂化生产拓展体力的工业革命后，人类正在历经以增强自我脑力为表征的信息革命。^②当前，人类社会已经进入互联网时代，人类社会在

* 本文系国家社科基金特别委托项目“社会治理法学原论”（16@ZH024）阶段性成果。

① 参见何明升：《中国网络治理的定位及现实路径》，《中国社会科学》2016年第7期。

② 从社会发展史看，人类经历农业革命、工业革命，正在经历信息革命。农业革命增强了人类生存能力，使人类从采食捕猎走向栽种畜养，从野蛮时代走向文明社会。工业革命拓展了人类体力，以机器取代了人力，以大规模工厂化生产取代了个体工场手工生产。信息革命则增强了人类脑力，带来生产力又一次质的飞跃，对国际政治、经济、文化、社会、生态、军事等领域发展产生了深刻影响。（参见习近平：《在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话》（2016年4月19日），《人民日报》2016年4月26日，第2版）





一定程度上就是网络社会。与农业社会的“地域性”熟人社会和工业社会的“中心—边缘结构”陌生人社会相比，网络社会是彻底打破边界的“去中心”脱域化社会，且正在突破领域、族阀的限制。^①以互联网为代表的信息技术革命在不断引领生产崭新变革、创造人类生活崭新空间和拓展国家治理崭新领域，^②推动网络社会迅速向更广、更深向度发展并彻底改变人类生产生活方式的同时，其治理问题也开始受到重视并日渐成为一个世界性难题。^③

网络社会是比现实社会更加复杂的技术结构兼社会结构的非线性运作状态，其治理问题是哲学社会科学研究的重点、难点问题，更是推进我国治理体系和治理能力现代化的题中应有之意。一方面，凭托于现代信息技术而存在的网络社会，正在打破一切分割人群的边界，信息可以穿过网络终端所及之处的一切边界，彻底改变工业社会权力和知识附属于地域的“硬件”时代，人们的生活从物理空间扩展到电子空间、数字空间、虚拟空间。网络社会的人们正生活在一个由自然、社会和虚拟空间构成的世界之中，更准确地说，网络社会的人们正穿梭于这三个世界之间。^④另一方面，十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》明确提出：“坚持积极利用、科学发展、依法管理、确保安全的方针，加大依法管理网络力度，加快完善互联网管理领导体制，确保国家网络和信息安全。”^⑤中共十八届四中全会通过的《关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确指出：“加强互联网领域立法，完善网络信息服务、网络安全保护、网络社会管理等方面的法律法规，依法规范网络行为。”^⑥这是国家对网络社会治理法治化问题从顶层设计

① 参见张康之、向玉琼：《网络空间中的政策问题建构》，《中国社会科学》2015年第2期。

② 参见习近平：《在第二届世界互联网大会开幕式上的讲话》（2015年12月16日），《人民日报》2015年12月17日，第2版。

③ 互联网技术的发展轨迹和全球网络治理的经验教训表明，谁负责全球互联网域名根服务器、域名体系和IP地址等的管理，占据网络社会技术发展优势和有效治理高地，谁就主导了“全球互联网大厦”根基的管控权，也就掌握了网络世界发展和治理规则的制定权，甚至获得以互联网信息技术为代表的信息革命时期的全球新生产力发展制控权。根服务器是国际互联网最重要的战略基础设施，是互联网通信的中枢。根服务器有13台，包括1个主根服务器（放在美国）和12个辅根服务器（9个放置在美国，英国、瑞典、日本各1个），所有根服务器均由美国政府授权的互联网域名与号码分配机构ICANN统一管理，负责全球互联网域名根服务器、域名体系和IP地址等的管理，这意味着极端情况下，世界其他国家有被互联网抹掉或拒绝网络服务的危险。（参见《全球互联网有望实现多边共治》，《科技日报》2015年6月24日，第1版）

④ 参见张康之、向玉琼：《网络空间中的政策问题建构》，《中国社会科学》2015年第2期。

⑤ 《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，北京：人民出版社，2013年，第51—52页。

⑥ 《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》，北京：人民出版社，2014年，第14页。



层面所作出的制度安排。尽管如此,学界对网络社会治理的相关探讨并不多见,缺乏对网络社会的基础研究,特别是“法治作为国家治理基本形式”的“法治中国”建设时代背景下,学界对网络社会治理法治化问题研究有待深入。

网络社会概念的界定,是网络社会治理法治模式及相关理论研究和学术对话的基点。其内涵是指网络社会质的规定性问题,外延是如何区分网络社会与传统社会,是判断标准问题,二者是网络社会概念厘定的两个核心问题。^① 学界关于网络社会及其判断标准的主流观点有二,一是把网络社会与农业社会、工业社会相对应,将其界定为一种新的社会形态。比如,卡斯特在其《网络社会的崛起》一书中认为,网络社会是指一个社会中关键的社会结构和社会行动都围绕着电子信息网络而展开的社会形式,其将网络社会定义为由信息时代支配性功能与过程日益以网络组织起来的一种新的社会形态。^② 童星主张把网络社会界定为“通过网络联系在一起的各种关系聚合的社会系统”,其与虚拟社会、信息社会的区别在于:虚拟社会是网络社会中的一部分,信息社会的涵义比较广泛,网络社会是它其中的一部分,网络社会有着与以前所有社会形态都不相同的特点,这些特点足以使之成为有别于以前所有社会形态的一种新的社会形态。^③ 另一种观点是把网络社会与现实社会相对应,将其界定为一种特殊的社会结构形态或者是一种社会形态中的特定空间(互联网空间)。比如:戚攻主张网络社会是现实社会的延伸并依存于现实社会,相对于现实社会结构而言,网络社会是一种中观的技术结构,是人类生活和工作的“另类空间”。^④ 郑中玉、何明升认为,所谓的网络社会并不代表一种单一网络形式的社会 and 高度整合的社会状态,只是一种社会结构形态,它是信息化社会的超文化和制度的基本结构逻辑和关键特色之一。^⑤ 这些对网络社会概念的界定,为理论与实践分析和研究网络社会形态中的社会活动,确认他人在这—社会结构中的地位作用提供了智力支持和现实指导。但网络社会“新的社会形态”和“一种社会形态的特定空间”概念界定的不一,直接带来研究和实践中对同一“网络社会”术语的异义适用,致使相关理论研究的深入和有效学术对话无法展开。

把握网络社会质的规定性是其概念研究的关键。借鉴信息工程学有关网络理论

① 参见魏屹东:《语境同一论:科学表征问题的一种解答》,《中国社会科学》2017年第6期。

② 卡斯特的网络社会“新的社会形态论”观点与其“网络社会是一种历史趋势”是一致的。(参见赵然:《网络社会中集体记忆研究的回顾与反思》,《新闻研究导刊》2017年第1期)

③ 童星、罗宇:《网络社会:一种新的、现实的社会存在方式》,《江苏社会科学》2001年第5期。

④ 参见戚攻:《网络社会在社会结构中的“位置”》,《社会》2004年第2期。

⑤ 参见郑中玉、何明升:《“网络社会”的概念辨析》,《社会学研究》2004年第1期。



的研究成果,^① 可将网络社会概括为, 公民、法人及其他组织以网络拓扑结构交互连通为基础, 通过数字信息和通信技术实现各种社会关系整合、再造而形成的一种特殊的社会结构形态, 是一个国家或地区占有一定网络资源、机会的社会成员的组成方式及其网络关系格局。在网络社会里, 基于互联网技术而形成了不同的新的社会关系, 但其质的规定性并未改变。本质上, 网络社会是公民、法人及其他组织等主体之间的各种关系基于互联网技术产生聚合而形成的新的社会关系格局和结构形态, 是现实经济、政治、文化、社会、生态领域各种关系的单一或综合反映、延伸和表达。网络社会实质上是一种数字化的社会结构、社会关系和社会资源的整合形态, 其关系网具有虚拟特征, 但事实上网络社会是一种客观存在。^② 把网络社会与农业社会、工业社会相对应, 将其界定为“一种新的社会形态”的观点, 忽略了网络社会的这一本质属性。正如马克思在分析社会的本质时指出, 社会是“人们交互活动的产物”, 即: 社会是人们相互交往的结果, 是人们之间普遍联系的表现, 无论社会表现为何种形式, 它的这种本质不会改变。^③ 网络空间是虚拟的, 但其事实却是一种客观存在。^④ 亦如马克思分析人的本质时所言, “因为人的本质是人的真正的社会联系, 所以人在积极实现自己本质的过程中创造、生产人的社会联系、社会本质”。^⑤ 网络社会表面上是无数终端的连接, 从而形成多点快速、互联互通的网状结构, 其实质连接的是作为生产、运用、管理信息的“人”, 而作为网络空间主体的人却是现实的, 其在积极实现自己本质的过程中创造、生产人的社会联系、社会本质。因此, 网络社会在其本质属性上并未超越马恩经典作家关于社会和本质的论断。

① 互联网基础结构历经从单个网络 ARPANET 向互联网、建成三级结构的互联网、逐渐形成了多层次 ISP 结构的互联网三个发展阶段, 以 Internet 为代表的计算机网络已从最初的仅供美国人使用的免费教育科研网络, 逐步发展成为供全球使用的商业网络, 成为全球最大的和最重要的计算机网络。信息工程领域关于计算机网络的精准定义并未统一, 经典的定义有两个: 一个认为, 计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互联而成的, 而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的 (例如, 传送数据或视频信号), 这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据, 并能支持广泛的和日益增长的应用; 另一个认为, 计算机网络是指把分布在不同地点且具有独立功能的多个计算机系统通过通信设备和线路连接起来, 在网络软件的支持下实现彼此之间数据通信和资源共享的系统。计算机信息工程学有关网络理论的创建, 为社会科学领域相关网络社会理论的研究提供了理论资源。(参见谢希仁:《计算机网络》, 北京: 电子工业出版社, 2017 年, 第 1—19 页; 参见徐红云:《大学计算机基础教程》, 北京: 清华大学出版社, 2014 年, 第 246 页)

② 熊光清:《推进中国网络社会治理能力建设》,《社会治理》2015 年第 2 期。

③ 《马克思恩格斯选集》第 4 卷, 北京: 人民出版社, 2012 年, 第 408 页。

④ 习近平:《在第二届世界互联网大会开幕式上的讲话》(2015 年 12 月 16 日),《人民日报》2015 年 12 月 17 日, 第 2 版。

⑤ 《马克思恩格斯全集》第 42 卷, 北京: 人民出版社, 1979 年, 第 24 页。





网络社会事实上客观存在将其与纯粹的虚拟社会区分开来；^① 与农业社会绝对的地域性熟人社会和工业社会因城市化、工业化而打破地域限制人们开始流动的陌生人社会相比，网络社会是一种新质的人—机共在模式，它通过网络技术使一切关系超越地理空间的限制，实现真正意义上的“脱域化”。具体而言，网络社会中人脑借助计算机进行数值、逻辑计算和存储记忆功能，使计算机按照程序自动、高速、有序处理海量数据，实现人类心智与计算机高性能的嵌合。这种良好嵌合的共存使得大数据的产生和处理得以实现，网络社会是信息以“爆炸式”方式存在的社会，同时，信息又借助于互联网技术的互联互通、交互连结而实现自身的多点快速传播、瞬间交流互动，信息被循环不断地“制造→传播→再制造”并以“散射状”形式彼此间交叉互动地辐射开来。网络社会里，“信息的发布者与接受者概念的区分被参与者概念所取代，每一个人都可以成为信息的创造者，而每一个人又同时是信息的消费者和传播者。网络上的‘自媒体’创造了一个互动的世界，在人际互动中，那些重大的、急迫的社会问题被遴选出来，并成为一种巨大的舆论（场）。 ”^② 这既是网络社会区别于工业社会、农业社会的体现，也是网络社会治理规则可介入（信息可控）的理论前提。因而，信息社会、数字社会、大数据时代等名称或术语，只不过是网络社会的一个侧面的概括或某一个显著特征的描述，其都被囊括在网络社会的范围内。同时，网络社会“一种社会形态中各种关系基于互联网技术产生聚合而形成的特定空间”的客观存在本质也决定了其同现实社会一样，应该且必然选择法治治理这一模式。

一、网络社会治理法治模式问题的提出

在实践中，伴随网络社会迅速向更广、更深向度发展而生的社会问题日益严峻，网络社会治理正在成为时代难题。截至 2016 年 12 月，中国网民规模达到 7.31 亿，相当于欧洲人口总数。2016 年与 2015 年比，互联网营销增长近一倍，网上支付年增长 14%。^③ 自 1994 年中科院计算机网络中心到美国加州 64Kbps 卫星专线的开通，全面开启我国互联网时代以来，23 年的网络社会发展进程，^④ 我国互联网普及率高达 53.2%，超过全球平均水平 3.1 个百分点，超过亚洲平均水平 7.6 个百分

① 参见熊光清：《推进中国网络社会治理能力建设》，《社会治理》2015 年第 2 期。

② 张康之、向玉琼：《网络空间中的政策问题建构》，《中国社会科学》2015 年第 2 期。

③ 参见中国互联网络信息中心（CNNIC）：《中国互联网络发展状况统计报告》，2017 年 1 月 22 日，http://www.cnnic.net.cn/hlwfzj/hlwxzbg/hlwtjbg/201701/t20170122_66437.htm，2017 年 4 月 21 日。

④ 参见《NCFC，中国互联网从这里起步》，2014 年 4 月 20 日，http://www.cctime.com/html/2014-4-20/2014420153117330_2.htm，2017 年 6 月 14 日。





点,其中手机网民达到了 6.95 亿,占比高达 95.1%,增长率连续三年超过 10%。^①“这是最好的时代。以互联网大数据为代表的这一次信息技术革命,将会对人类社会产生极大推进作用。但这也是最坏的时代。像不久前爆发的勒索病毒一样,各种利用互联网技术偷盗、诈骗、敲诈等案件不断发生,各种围绕互联网的黑灰产业正以极快的速度蔓延。”^②在我国网络社会互联网技术和实体经济深度融合发展,以信息流带动技术流、资金流、人才流、物资流,促进资源配置优化,促进全要素生产率提升,为推动创新发展、转变经济发展方式、调整经济结构发挥积极作用的同时,诸多社会问题也油然而生。^③据统计,2015 年我国每 10 万人中发生杀人案件 0.67 起,是世界上杀人案件发案率最低的国家之一,而网络犯罪则占犯罪总数的近三分之一,且每年增加近 30%。^④从主要国家的统计数据看,各种利用互联网技术实施偷盗、诈骗、敲诈的案件数每年以超过 30%的增速在增长。据测算,仅中国“网络黑产”从业人员就已超过 150 万,市场规模也已高达千亿级别。^⑤当前,网络社会发展不平衡、规则不健全、秩序不合理等问题日益凸显,^⑥网络社会出现的网络犯罪、网络黑客攻击、网络病毒入侵、网络信息泛滥与垄断、网络安全威胁、网络成瘾问题,等等,都对人们的生活和生产造成巨大威胁。如何有效应对这些网络社会问题,保障网络社会健康发展已然成为时代难题。

网络社会现实问题日渐凸显和传统治理模式无法有效规制的冲突与尴尬局面正在发生。在社会生产力革新和人类文明发展的漫长曲折历程中,以人一机共在模式而存在的高技术信息革命跨越了以增强人类体力为表征的工业革命,人类进入网络社会时代。以增强人类脑力为表征的网络社会,与农业革命使人类从采食捕猎走向栽种畜养,增强生存能力的农业社会有明显区别;也与工业革命以机器取代人力,以大规模工厂化生产取代个体工场手工生产,拓展人类体力有着本质

- ① 参见中国互联网络信息中心 (CNNIC):《中国互联网络发展状况统计报告》,2017 年 1 月 22 日, http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxyzbg/hlwtjbg/201701/t20170122_66437.htm,2017 年 4 月 21 日。
- ② 《2017 网络安全生态峰会在京举行 共议网络新安全挑战》,2017 年 7 月 26 日, http://news.xinhuanet.com/legal/2017-07/26/c_129664264.htm,2017 年 7 月 27 日。
- ③ 参见习近平:《在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话》(2016 年 4 月 19 日),《人民日报》2016 年 4 月 26 日,第 2 版。
- ④ 孟建柱:《网络犯罪已占犯罪总数近三分之一》,《北京青年报》2016 年 10 月 14 日,第 8 版。
- ⑤ 《2017 网络安全生态峰会在京举行 共议网络新安全挑战》,2017 年 7 月 26 日, http://news.xinhuanet.com/legal/2017-07/26/c_129664264.htm,2017 年 7 月 27 日。
- ⑥ 互联网在发挥促进全要素生产率提升、推动创新发展积极效用的同时,其负面问题也日渐显露。(参见习近平:《在第二届世界互联网大会开幕式上的讲话》(2015 年 12 月 16 日),《人民日报》2015 年 12 月 17 日,第 2 版)



不同。基于人一机共存实现了自我心智延伸和脑力增强的网络社会，其治理模式也注定与传统增强生存能力的农业社会和延伸肢体、增强体力的工业社会治理模式有所不同。借助现代数字通信和网络技术而实现的人—机良好嵌合，是以增强脑力为鲜明表征的网络社会的存在和不断向更深、更广向度发展的前提要件，这决定了网络社会治理必然突出技术的转化与驯服和网络空间良好秩序的构建。因此，抓住治“机”与治“网”这个关键是网络社会治理模式必须关照的独特内容和核心要素。网络社会里，“网络加速了制度的抽离和中心—边缘结构的解体，同时推动了问题的再嵌入。问题一方面似乎飘散到了遥远的地方而显得更加抽象了，另一方面，又被推到了每一个人面前，从而显得更加具体了”。^① 网络社会问题表现出信息传播超地域性、瞬息化，参与主体不确定、广泛性，社会影响波及面大、短时间内防控可能性小等特点，对基于原有社会形态而来的社会治理范型和模式提出了崭新挑战。网络安全保护、网络社会秩序维护、网络信息管理及风险防控问题的不断出现和无序发展，既反映出网络技术在我国飞速发展和广泛应用，也显现出既有治理范型与模式面对网络社会新问题无法及时有效应对的无力。在利益格局多元的网络社会中，这种现实问题日渐凸显和传统治理模式无法有效规制的冲突与尴尬局面的发生也迫使理论界作出回应。

在这样的技术、社会背景下，非基于“技术归化”^② 而来的治理模式自身设计存在一定的缺陷，探究新的社会治理模式成为研究的重点难点。随着网络社会问题的日益增多和治理实践探索的深入，理论界开始关注并出现了不同的网络社会治理范型与模式。有的是基于“多主体协同治理”提出的治理模式，强调治理主体的多元、多级或者是自由、民主价值的实现。如，联合国提出的“多利益攸关方治理模式”；^③ 丹麦学者伊娃·索伦森提出的“民主治理模式”；^④ 丹伯格提出的“自由主义模式”、“社群主义模式”和“协商民主模式”；^⑤ 欧盟提出的“多层级治理模式”等。^⑥ 有的是基于“网络空间边界”而提出的治理模式，强调的是网络空间的无界理论与主权治理，如张新宝等提出的“网络空间主权治理模式”。这些网络社会治理

① 张康之、向玉琼：《网络空间中的政策问题建构》，《中国社会科学》2015 年第 2 期。

② 技术归化是指，各种新技术必须得到转化，使其从陌生的、可能有的危险东西转化成能够融入社会文化和日常生活之中的驯化之物。（参见何明升：《中国网络治理的定位及现实路径》，《中国社会科学》2016 年第 7 期）

③ Working Group on Internet Governance, “Report from the Working Group on Internet Governance,” Document WSIS-II/PC-3/DOC/5-E, August 2005, p. 3.

④ Eva Sørensen and Jacob Torfing, “Theories of Democratic Network Governance,” *Public Administration*, vol. 86, no. 3, 2008, pp. 859-862.

⑤ 参见曾润喜：《中国互联网虚拟社会治理问题的国际研究》，《电子政务》2012 年第 9 期。

⑥ 参见张康之、程倩：《网络治理理论及其实践》，《新视野》2010 年第 6 期。



范型与模式的研究与探讨,对现实网络社会问题的解决发挥了重要积极作用,为网络社会相关学术研究的深入开展提供了有力的智识资源,但这些非基于技术归化而来的传统治理模式能否有效应对网络社会的高速发展仍有待观察和验证。在长期的认识世界和改造世界活动中,人类通过“代码”这一网络内在生存密码和存在逻辑,首次通过心智与技术的良好契合,实现人类社会生产力的又一次质的飞跃,进而构成人类历史发展阶段上独特的网络社会。因此,凭托互联网技术而首次实现人类脑力增强的网络社会的独特性和技术的社会工具性,^①决定了技术归化是网络社会治理的必然要求和核心内容,但既有的网络社会治理模式及其理论并非基于技术归化理论而来。随着网络越来越发达,人际关系在疏离和稠密之间变得难以判断,也使人们的在场与缺席难以捉摸。“现代国家所依靠的是通过抽象系统而进行治理,具体的行动所依据的是抽象的制度和规则体系,然而,网络上出现的却是行动的具体性,不受抽象的制度和规则体系的制约,同时,人际关系的相邻性和互动性又是前所未有的。”^②显然,现代国家基于抽象系统进行治理的理论无法适应网络社会行动的具体性变化。同时,上述非基于技术归化而来的治理模式自身设计也存在一定的缺陷,有的甚至存在正当性、有效性理论缺失的弊病。比如,自由主义模式、民主治理模式以及多利益攸关方治理模式,看似是自由、民主、平衡各方利益的完美方案,强调自由、民主、平等价值的实现,实则陷入了理论幻想的乌托邦,这类模式注定因缺乏操作性而不可能实现;而主权治理模式和全球公域理论的背后是主权利益的恪守与新霸权主义的延伸,两种模式是对网络空间范围边界的探讨,更强调政治理性的选择。从政治范畴与视角出发,我们支持“主权治理模式”及其相关理论。^③因此,一种新的基于技术归化而来的法治治理理论、制度与实践相结合的网络社会治理模型与范式亟待出现,即网络社会治理的“法治模式”。

二、网络社会治理法治模式的法理蕴涵与正当基础

(一) 网络社会治理法治模式的法理蕴涵

网络社会治理法治模式,是指坚持运用法治思维和法治方式,将网络社会治理要素、治理结构、治理程序、治理功能纳入法治范围及运行轨道协调统一的有机综

① 技术始终应该是用于满足各类社会需要的工具,互联网技术注定是社会的工具。(参见何明升:《中国网络治理的定位及现实路径》,《中国社会科学》2016年第7期)

② 参见张康之、向玉琼:《网络空间中的政策问题建构》,《中国社会科学》2015年第2期。

③ 网络空间主权是我国处理网络事务的根本指针,张新宝、许可提出的“主权治理模式”是对“全球公域”理论的有力回应。(参见张新宝、许可:《网络空间主权的治理模式及其制度构建》,《中国社会科学》2016年第8期)



合体及其治理理论、制度与实践。在理论层面，基于我国网络社会发展和法治建设的制度和实践，通过科学阐释网络社会的内涵与外延，探究网络社会治理法治模式的正当性和可行性，以推进我国网络社会治理现代化法治化为目标，构建集中体现人民意志和社会主义属性的中国特色网络社会治理模式及理论。在制度安排层面，中国特色网络社会治理法治模式的制度要素构成包括：网络社会治理法律规范体系完备，网络社会治理法治实施体系高效，网络社会治理法治监督体系严密，网络社会治理法治保障体系有力。实践层面，公民、法人及其他社会组织基于法治治理理论指引和制度规范，通过法律规范、行政监管、行业自律、技术保障、公众监督、社会教育等规则体系的实施与运行，运用网络技术与依托社会规则规范，对网络信息技术、物理、设施运行安全及网络行为进行规范调整，使一切网络社会治理活动在法治的轨道上健康有序运行。

网络社会治理法治模式的内容，强调通过运用法治思维和法治方式依法治网、办网、用网、护网，实现对网络社会的有效治理。规则之治是法治首要的特点，^①在法治和网络社会的关系中，作为法治的规则之治是治理手段，稳定、有序和可预期网络社会的建立是目的，运用法治思维和法治方式依法治网、办网、用网、护网是适用法治治理手段实现网络社会治理目的的过程。经济健康发展、技术创新进步、稳定安全有序、平等开放共享的网络社会的建立和形成，运用法治思维和法治方式依法治网、办网、用网、护网并将其全部环节和一切过程纳入法治轨道是必然要求和核心内容。其中，治网要求国家治理网络在法定范围内进行。国家网络立法严格落实《立法法》规定，坚持立改废释并举，完善网络治理行政法规、规章制定程序，健全政府网络立法立项、起草、论证、协调、审议机制，增强网络立法精细化、及时性、系统性、针对性、有效性；严守“法定职责必须为、法无授权不可为”的原则，建立治网权力清单、责任清单、负面清单制度并实行动态管理，将政府网络治理的法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项以权力清单的形式向社会公开，推进政府网络治理机构、职能、权限、程序、责任法定化。办网要求网络生产、运营、服务组织者在提供网络设施设备、技术平台及服务过程中，不仅仅要求其必须具有现实社会公司法人相同的适格法定从业资质、能力、条件（专利技术、场地、资金）等，接受行政许可审批、遵守法定义务、遵循市场规则，而且要求其所构建的网络虚拟空间及其提供的服务必须遵守国家法律、行政法规、行业规范、技术规程，不得违反公序良俗，使其“办网”活动始终在法治的范围与轨道上运行。用网要求网络产品、技术和服务的制造者、销售者和消费者利用网络技术开展经济社会活动应当在法治范围内进行，遵守公序良俗基本原则。网络产品、技术、服务制造者和销售者利用互联网技术在网络空间开展经济社会活动，

① 参见朱景文：《论法治评估的类型化》，《中国社会科学》2015 年第 7 期。



必须遵守网络治理法律法规、行业规范,在法治范围内提供优质、合法、健康的网络产品和服务,依法享有使用网络权利和履行法定义务;网络消费者消费网络服务和产品,应遵守网络社会消费者法律规则。依法用网要求所有用网主体在网络空间内依法依规依章行使知情权、表达权、参与权、监督权,使其实现法律所赋予的各项权利及履行法定义务都在法治轨道上进行。护网要求全社会自觉树立法律观念和诚信意识,自觉肩负保护网络空间、营造健康网络环境、共建良好网络秩序的神圣使命,形成全社会依法“护网自觉、护网有责、护网光荣”的网络社会良好风气。

网络社会治理法治模式包含了若干要素:其一,该模式始终坚持法治为核心,自觉把网络社会治理法治贯彻到理论研究、制度安排、实践探索的全过程。其二,该模式采取发展与安全并重治理原则,强调既要尊重网民交流思想、表达意愿的自由与权利,也要依法构建良好网络秩序,遵循网络社会创新发展与安全有序保障并重。其三,该模式坚持规则治理,明确赋予各参与方相应的权、责、利,科学诠释网络社会法律关系的主体、客体、内容、性质、特征、结构形态及运行,强调网络社会治理法律规则的制定、遵守、执行和适用,确保一切治理活动在规则的范围内和轨道上健康有序运行。

(二) 网络社会治理法治模式的正当基础

网络社会治理,是政府、私营部门和民间社会根据各自的作用,制定和实施的旨在规范互联网发展和运用的共同原则、规范、规则、决策程序和方案,其治理模式问题是当今世界共同面临的时代难题。^① 网络社会人脑心智与计算机性能良好嵌合的人—机共在模式决定了其治理模式的选择既要汲取已有模式的有益成果,又要体现网络社会技术归化的独特性。法治作为规则之治、良法之治,是现代文明国家治理的最佳选择和基本形式。^② 网络社会里秩序既是内嵌其中代码技术规则体系自身构建的前提,也是网络技术发展进程中社会选择、技术引领和秩序再造的目标追求。法治治理模式作为现代文明中社会价值共识的最大公约数和最大保险系数,是保障技术应用所进行的社会选择过程在有序的轨道上运转,实现网络社会治理技术归化,推进网络社会治理体系和治理能力现代化的最佳选择和必由之路。

第一,网络社会的本质决定了其同现实社会一样,需要且必须循法治之路,选择法治治理模式。网络主体趋虚拟化之潮涌向现实,使社会“二重化”分为现实社

① Working Group on Internet Governance, “Report from the Working Group on Internet Governance,” Document WSIS-II/PC-3/DOC/5-E, August 2005, p. 3.

② 参见徐汉明、张新平:《社会治理法治建设指标体系的设计、内容及其评估》,《法学杂志》2016年第6期。



会和网络社会,二者之间存在着互动关系。^①网络社会的线上与线下、虚拟与实体的互动交流是社会“二重化”的结果,这没有从本质上改变网络社会具有同现实社会一样的社会属性,没有超越马恩经典作家的社会本质论。网络社会存在机制实质上是一种新质的共在模式,它实现了人一机交互的生存方式,使人的心智与计算机的高性能得到良好嵌合。^②说到底,网络社会依然是人们(通过技术)交互活动的产物,是人们之间(通过技术)普遍联系的表现,无论社会表现为何种形式,它的社会本质不会改变,即:网络社会表面上是无数终端的连接,实质是作为生产、运用、管理信息的“人”的连接和操控,而作为网络社会主体的“人”确是客观存在的。只不过,基于互联网技术而产生的网络社会,“人”不仅可以摆脱时空的束缚而随时随地进行表达,而且可以时时刻刻地影响“他人”并被“他人”影响。因此,网络空间是虚拟的,但基于数字化的社会结构、社会关系和社会资源整合而来的网络社会是客观存在的,运用网络空间的主体是现实的。网络虚拟空间中政府与网络社会组织及网民所构成的权利与义务、职权与责任、管理与被管理、合作与互动、活力与秩序、自由与自律、规则与道德等错综复杂的社会关系,本质上是现实领域各种关系的反映、延伸和表达,其与现实社会一样,既要提倡自由与活力,也要保持自律与秩序,既要尊重网民交流思想、表达意愿的权利,也要依法构建良好网络秩序,而这些都是都需要且必须遵守法治,选择法治之治,走法治之路。^③网络社会在本质上没有超越马恩经典作家关于社会形态的本质论,决定了网络社会治理与现实社会一样,必然选择法治治理这一模式。

第二,法治模式是网络社会治理目标实现的最佳选择。无论何种治理模式的研究探索,其出发点都是围绕网络社会治理的根本目标展开。对我国而言,网络社会治理的目标和宗旨在于使网络社会健康有序运行,实现网络社会的稳定和谐。对于世界而言,网络社会治理以人类共同福祉为根本宗旨,通过保障网络物理安全、网络安全、网络运行安全以及网络空间活动良好秩序,推动全球互联网治理向更加公正合理方向迈进,进而推动网络空间实现平等尊重、创新发展、开放共享、安全有序目标的实现。^④“法者,天下之公器”,一方面,网络社会这些治理目标的实现离不开法治的有力保障。另一方面,法律是治国之重器,法治是社会价值共识的最大公约数,在利益多元的网络社会中,法治是其健康有序运行目标实现的最大保险系数。运用法治思维和法治方式依法“治网、办网、用网、护网”,提高网络社

① 参见谢俊:《社会“二重化”与网络社会安全建构》,《理论月刊》2017年第2期。

② 何明升:《中国网络治理的定位及现实路径》,《中国社会科学》2016年第7期。

③ 习近平:《在第二届世界互联网大会开幕式上的讲话》(2015年12月16日),《人民日报》2015年12月17日,第2版。

④ 《携手构建网络空间命运共同体》,2016年11月17日, <http://news.sina.com.cn/c/2016-11-17/doc-ifxxwmws3004755.shtml>, 2016年12月24日。



会治理法治化水平,既是实现网络社会在法治轨道上健康有序运行发展,提高网络社会治理法治化水平,推进包括网络社会在内的国家治理体系和治理能力现代化的必由之路;也是中国作为世界网络空间的建设者、维护者和贡献者,维护我国网络空间主权和安全,构建全球网络空间发展和治理新秩序,实现建设网络强国宏伟目标和中华民族伟大复兴中国梦的重要途径。

第三,网络社会的独特性决定了网络社会法治治理的难度更大,更需要且必须循法治之路,选择法治治理模式。网络社会的本质决定了其是一种客观存在,是现实各种关系在网络空间的反映、延伸和表达。但是,“生产关系总合起来就构成所谓社会关系,构成所谓社会,并且是构成一个处于一定历史发展阶段上的社会,具有独特的特征的社会。”^①因此,网络社会又有其相对的独特性,而其自身的匿名、开放、高度自治等内在特点和网络社会利己主义无需规范与现实社会中集体主义的行为规范发生激烈冲突等决定了对其进行法治治理的难度更大。一方面,与传统社会相比,网络社会提供了更加宽松自由的参与环境,大大激发了社会成员的参与活力,大量新型法律关系在虚拟化、复杂化的网络社会中产生出现,必然使网络社会法治治理的难度加大。另一方面,网络社会自身的匿名、开放、高度自治等内在特点,为网络虚拟社会参与者摆脱传统社会角色、社会地位、社会责任关系束缚提供了条件和可能,既有传统社会伦理、法律失灵失范,甚至治理规则缺失,必然使网络社会法治治理难度加大。再一方面,网络社会的多点快速、互联互通、交互连接等,使得网络社会法律关系的主体更加多元,法律关系的内容更加纷繁复杂、法律关系保护的客体法益更加多种,法律行为的形式更加多样,全球互联互通使得法律管辖地域确定更难,法律空间范围更广,国际司法合作挑战更大,等等。这些都决定了网络社会的治理比传统社会难度更大,更需要走法治之路,选择法治治理模式。

总之,网络社会治理走法治之路,选择法治治理模式,有其必然性和正当性理论基础。唯有实行法治,诠释网络社会法律关系的性质、特征、结构形态及运行等基本法律问题,界定网络社会治理法治模式的主体与客体、权利与义务、个人与社会、自由与秩序、自治与共治等基本法权关系,坚持运用法治思维和法治方式,在法治范围内“治网、办网、用网、护网”,才能让网络社会在法治的轨道上健康有序运行。

三、我国网络社会治理法治建设的实践探索

新中国成立以来,经济社会发生了巨大而深刻的变化,社会治理体制也在不断

^① 《马克思恩格斯选集》第1卷,北京:人民出版社,2012年,第340页。



调整和变革之中。^① 其中,自 1994 年 4 月 20 日被国际上承认为第 77 个真正拥有全功能 Internet 的国家正式进入网络时代以来,我国开启了曲折的网络社会以及网络社会治理法治建设实践探索之路。^② 我国网络社会治理法治建设的实践探索以传统电信、邮电、邮政、广播、电视事业时代社会管理的实践为基础,历经产生和不断发展,正处于向运用法治思维和法治方式治网、办网、用网、护网的网络社会治理法治化跨越转型阶段。概括起来,以 1994 年进入网络社会为标志,我国网络社会治理法治建设的实践探索可分为起步、发展和转型三个阶段。

(一) 我国网络社会治理法治建设的实践探索之路

1. 网络社会治理法治建设的起步阶段(1994—2003)。我国网络社会治理法治建设的实践探索是在传统电信、邮电、邮政、广播、电视事业“多元主体、上下统一、集中管控”管理体制的基础上开始的。1949 年《中央人民政府组织法》规定设立邮电部,国家对邮电等采取“统一领导,分别经营,垂直系统”的管理体制,^③ 电信、邮电、邮政、广播、电视行业顺应时代潮流,围绕国民经济三年恢复计划,“一五”、“二五”国民经济及社会发展计划的实施而逐步发展起来。其后受历史影响,十年“文化大革命”期间,管理体制实行高度集中的行政管控模式,电信管理法律法规基本空白。^④ 改革开放后,为适应“以经济建设为中心”的任务要求,国家对邮政、电信、广播、电视等行业实行“分业管理、条块结合”管理体制和运行模式。这一时期,国家颁布了《邮政法》等规范性文件。^⑤ 这些法律制度颁行实施及实践探索使我国网络社会治理法治建设的起步和发展成为可能。1994 年在 NCFC 工程的推动下中国正式步入网络社会,^⑥ 开启我国网络社会治理实践探索之路。随着互联网技术的普及和发展,网络社会治理问题不断凸显,网络社会治理法治建设

① 参见李培林:《创新社会管理是一项社会体制改革》,《人民日报》2011 年 12 月 13 日,第 7 版。

② 参见王绍光:《中国公共政策议程设置的模式》,《中国社会科学》2006 年第 5 期。

③ 参见 <http://www.diyitui.com/content-1442454595.34834401.html>, 2016 年 10 月 23 日。

④ 参见尔泰:《中国广播电视管理史概说》,《视听界》1989 年第 1 期。

⑤ 这一阶段相继颁布的规范性文件有:《关于建立电影放映网与电影工业的决定》(1954)、《关于地方人民广播电台管理办法的规定》(1955)、《关于设置和使用无线电台的管理办法》(1963)、《关于严格禁止国际电话与专线台设在一起的通知》(1974)、《外事电信通信组织管理有关规定》(1977)、《邮政法》(1986)、《关于保护通信线路的规定》(1982)、《广播电视设施保护条例》(1987)、《卫星电视广播地面接收设施管理规定》(1993)、《电信通信指挥调度制度》(1979)、《关于加强查处破坏邮政通信案件工作的通知》(1983)、《关于严防发生爆炸破坏案件保卫邮电通信安全的通知》(1989)等。

⑥ 参见闵大洪:《中国“网民节”该定哪一天?》,《中国社会科学院报》2009 年 6 月 16 日,第 6 版。



开始被关注和重视起来。针对起步阶段互联网领域网络犯罪活动猖獗、计算机病毒频发、盗版软件、垃圾信息、广播电视传输设施侵占破坏、电信垄断、隐私侵权等问题,国家先后颁布了 15 部法律法规对其进行规制。^①特别是在惩治和预防网络犯罪方面,针对计算机犯罪日趋严重的情况,全国人大常委会审议通过《刑法》(1997 年修订),^②明确对侵入计算机信息系统,故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序的罪名及犯罪的刑事责任,从保障网络安全,维护社会主义市场经济秩序和社会管理秩序,保护公民、法人和其他组织的合法权益等方面明确了利用互联网实施违法行为的法律责任。^③

2. 网络社会治理法治建设的重点突破发展阶段(2004—2012)。信息技术飞速发展给经济社会注入活力的同时,也带来了网络安全风险加剧等诸多挑战。这一阶段,针对网络著作权保护、安全保护技术、网络金融安全保障、个人信息安全保护、网络安全应急等突出问题,我国颁布了《互联网络域名管理办法》、《互联网安全保护技术措施规定》、《电子签名法》等相关规范性文件。^④惩治和预防网络犯罪方面,针对计算机犯罪形式多样化,提供或利用非法程序实施互联网违法犯罪活动日趋增多等问题,全国人大常委会 2009 年审议通过了《刑法修正案(七)》,明

① 这一阶段先后颁行 15 部法律法规:《计算机信息系统安全保护条例》(1994)、《计算机信息网络国际联网管理暂行规定》(1996)、《计算机信息系统保密管理暂行规定》(1998)、《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》(2000)、《计算机病毒防治管理办法》(2000)、《中华人民共和国电信条例》(2000)、《互联网电子公告服务管理规定》(2000)、《互联网信息服务管理办法》(2000 年制订,2011 年修订)、《互联网药品信息服务管理暂行规定》(2001)、《互联网上网服务营业场所管理办法》(2001)、《互联网医疗卫生信息服务管理办法》(2001)、《网上银行业务管理暂行办法》(2001)、《计算机软件保护条例》(2001 年公布,2013 年修订)、《互联网出版管理暂行规定》(2002)、《互联网文化管理暂行规定》(2003)。

② 王汉斌:《关于〈中华人民共和国刑法(修订草案)〉的说明》,《人大工作通讯》1997 年第 Z1 期。

③ 杨景宇:《关于〈关于维护网络安全和信息安全的决定(草案)〉的说明》,《中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会公报》2001 年第 1 期。

④ 这一阶段陆续出台 17 部法律法规:《中国互联网络域名管理办法》(2004)、《互联网药品信息服务管理办法》(2004)、《电子银行业务管理办法》(2005)、《电子认证服务管理办法》(2005)、《非经营性互联网信息服务备案管理办法》(2005)、《互联网著作权行政保护办法》(2005)、《关于网络游戏发展和管理的若干意见》(2005)、《信息网络传播权保护条例》(2006)、《互联网电子邮件服务管理办法》(2006)、《中国互联网络信息中心域名争议解决办法》(2006)、《互联网安全保护技术措施规定》(2006)、《关于进一步加强网吧及网络游戏管理工作的通知》(2007)、《互联网视听节目服务管理规定》(2007)、《电子出版物管理规定》(2007)、《电子认证服务管理办法》(2009)、《网络运行和信息安全保密管理办法》(2010)、《通信网络安全防护管理办法》(2010)。



明确规定非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统,提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具等犯罪行为的刑事责任,为惩治和预防网络犯罪提供了刑事法律保障。网络信息保护方面,全国人大常委会2012年审议通过了《关于加强网络信息保护的决定》,明确保护个人电子信箱、网络身份管理规范、网络服务提供者义务、主管部门监管手段等,为加强个人电子信息保护、维护网络信息安全提供了法律依据。这些制度安排对网络著作权与传播权保护、网络域名备案管理、网络运营服务安全管理、网络信息管理、网络金融安全、个人信息安全保护、网络安全突发事件应对处置等进行规范与调整,对保障我国当时网络社会安全起到了显著效果。这为其后我国的网络社会治理法治建设转型奠定了基础,创造了良好的制度条件和法治环境。

3. 网络社会治理法治建设的跨越转型阶段(2013年至今)。2013年,十八届三中全会“坚持积极利用、科学发展、依法管理、确保安全的方针,加大依法管理网络力度,加快完善互联网管理领导体制,确保国家网络和信息安全”顶层制度的设计安排,标志着我国网络社会治理法治建设开始向保障运用法治思维和法治方式“治网、办网、用网、护网”阶段跨越转型。这一阶段,网络技术广泛运用在给国民经济社会带来诸多发展机遇的同时,也带来了许多新的现实挑战及难以预见的风险。面对网络社会非传统领域安全问题日益凸显,网络入侵、网络攻击、宣扬恐怖主义、极端主义以及淫秽色情等违法与犯罪信息泛滥、用户账号管理、网络交易资金安全、搜索引擎管理等急迫问题,国家从顶层制度设计层面明确提出“加强互联网领域立法,完善网络信息服务、网络安全保护、网络社会管理等方面的法律法规,依法规范网络行为”,并先后颁布了《网络交易管理办法》、《互联网用户账号名称管理规定》、《网络安全法》等法律规范对这些问题进行规范与治理,^①对保障网民合法权益,维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益,促进经济社会健康发展和和谐稳定起到了积极作用。特别是针对网络犯罪新形式及其危害的惩治与预防,全国人大常委会2015年审议通过了《刑法修正案(九)》,界定侵犯公民个人信息、网络服务提供者不履行安全管理义务、扰乱无线电秩序、传播虚假信息、破坏计算机信息系统等犯罪行为的刑事责任,从刑事法律规范层面为惩治和预防网络犯罪提供了刑事法律保障。同时,为应对新时期网络社会治理领域出现的上述新问题,根据我国网络社会法治建设实践探索的实际情况,党中央从国家安全和长远发展出发,成立了旨在制定网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策,推动国家网络安全和信息化法治建设的中央网络安全和信息化领导小组,这为新时期我国网络社会

^① 这一阶段颁布的有:《国家安全法》(2015)、《网络交易管理办法》(2014)、《互联网用户账号名称管理规定》(2015)、《互联网保险业务监管暂行办法》(2015)、《网络出版服务管理规定》(2016)、《网络安全法》(2016)等。



法治治理提供了坚实有力的制度保障。

（二）我国网络社会治理法治建设的思考

回首 23 年中国网络社会治理法治建设的实践探索之路，独具中国特色的网络社会治理法治体系基本构建，彰显中国特色的网络社会治理法治理论基本形成。中国网络社会治理法治建设的实践探索，既为推进我国网络社会治理法治化和全球网络社会治理提供了新鲜经验，但也存在保障运用法治思维和法治方式“治网、办网、用网、护网”困难诸多等薄弱环节。

1. 我国网络社会治理法治建设的基本经验

第一，坚持从国情出发与有益经验借鉴相结合。纵观我国网络社会治理法治建设实践历程，我国始终从网络社会治理所面临的世情、国情出发，重视网络社会治理法治建设，以适应网络信息技术革命后的国际崭新格局和网络时代国家治国理政与经济社会发展的现实风险和挑战。自 1994 年以来，为适应经济全球化、政治多极化、文化多样化、治理多元化、信息现代化交融发展的国际趋势，有效应对国内网络犯罪活动猖獗、计算机病毒频发、盗版垃圾信息泛滥、网络恐怖极端主义、国家安全威胁、网络虚假等新情况、新问题。我国从“以经济建设为中心”的国情和“全球化”的世情出发，学习借鉴发达国家关于网络物理安全、技术安全、运行安全等基础性制度建设及网络社会治理方面的有益治理经验，始终关注全球网络法治建设的新成果、新制度、新方式，借鉴有关国家网络社会治理先进立法技术和治理成果，出台了《电子签名法》、《网络安全法》等一系列法律规范，形成了我国网络社会治理法治建设的“后发优势”。坚持从国情出发与有益经验借鉴相结合，我国网络社会治理法治建设正逐渐向体现网络社会治理法治建设时代性，把握网络社会治理法治建设规律性，具有网络社会法治体系科学性，维护国家网络空间主权坚定性的方向发展。

第二，坚持问题导向与制度建设相结合。我国网络社会治理始终坚持以问题为导向，面对不同时期出现的不同问题，始终重视治理法律制度建设，坚持法治方式进行治理。网络社会起步和发展阶段面对网络领域出现的网络赌博、诈骗、计算机病毒、盗版垃圾信息等问题，国家先后出台《互联网著作权行政保护办法》等多部法规规范。转型新时期，网络极端恐怖主义、网络用户信息保护、账号安全、网络交易信用障碍、网络金融资金安全、搜索信息推广等新问题不断出现，国家出台了《网络安全法》等一系列法规规范，以应对现实问题及预防未知风险。坚持问题导向与制度建设相结合，重视网络治理法律制度建设，我国正逐步形成从点到面的网络治理法规体系建设，不断走向从“被动性与跟进式”的行政法规体系的搭建到网络社会治理基本制度法律框架的空间预留，取得了良好治理效果。

第三，坚持安全保障与发展并重。中共十八届三中全会确立的“积极利用、科



学发展、依法管理、确保安全”的互联网发展方针，明确了我国网络安全与网络发展的关系，两者互为表里、协调一致、齐头并进。这既是我国网络社会治理实践探索经验的高度凝练与概括，也是对网络社会治理实践教训的深刻反思。自步入网络社会以来，随着计算机和智能手机的普及和应用，网络已然成为现代社会工作和生活的必需品。网络无纸化办公、信息零延迟传送、可视化交流等等，互联网领域的 E-mail、微博、微信、QQ、贴吧等网络软件的广泛使用，网络在带给人们低成本、高效率、优质的服务，推动经济社会快速发展的同时，网络域名安全、网络金融安全缺乏保障、个人信息安全亟待加强、国家安全、网络安全应急机制体系尚不完善等突出问题也日益受到关注。为此，我国相继颁布《电子签名法》等规范性文件，重点关注网络治理与网络安全保障问题。转型发展新时期，为保障网络安全，维护网络空间主权和国家安全、社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进经济社会与信息现代化协调发展，国家专门出台了《网络安全法》，并明确提出国家“坚持网络安全与信息化发展并重”的基本原则。总之，我国始终注重网络安全制度建设的同时，注意保护各类网络主体的合法权利，保障网络信息依法有序自由流动，通过保障网络空间主权安全为发展提供良好环境，促进网络技术创新和信息化持续健康发展。

2. 我国网络社会治理法治建设面临的现实困境

第一，网络社会治理立法存在一定不足。问题导向下的网络社会治理顶层制度设计和基础性法律规范制定存在“头疼医头、脚疼医脚”被动跟进、应急出台现象，造成网络社会治理立法缺位甚至空白问题。立法制度安排无法应对网络社会治理日益复杂的新形势、新形态、新特点及新问题。例如，《网络安全法》作为网络安全管理方面的基础性法律，既是被动跟进、应急出台立法实践的产物，也因自身框架结构设计问题而受到关注。^① 如何为制定配套法律法规预留接口，仍是加快建设网络社会治理法治体系悬而未决的重大问题。被动立法直接带来的是《网络信息保护法》等立法的缺位，甚至存在重要领域立法空白的问题。网络技术迅猛发展催生网络社会新业态，网络经济组织层出不穷，对国家网络社会立法带来挑战。诸如对网络社会的虚假伪劣产品整治、电商微商准入、网络知识产权保护、网络运营商的义务和社会责任、网络消费者权益保护、网络执法司法管辖、电子证据规则、个人信息保护及数据保密等的法律规则的制定，都是网络社会立法的棘手难题。同时，网络空间全球“互联互通”、“地球村”的特性和国际背景滋生含有大量境外因素的网络安全威胁、技术入侵问题，因为相关立法缺失、甚至空白而无法有效应对与治理。

第二，网络社会治理执法面临诸多困境。网络社会执法涉及职能机构、主管部

① 参见丁道勤：《“上天入地”，还是“度权量利”——〈网络安全法（草案）〉述评》，《中国矿业大学学报》2016 年第 3 期。



门、协助单位的职能分工、职权设定、程序设置、监督制约、协调配合等某些缺陷,导致我国行政机关在“治网”中存在“九龙治水水成龙”现象。具体根据各行政机关“治理网络”的动因,可将我国治网主体分为四大类。一是通信业管理部门。即工业和信息化部及对应地方机关,主要管理网络通信,指导推进网络信息化建设,协调维护国家网络信息安全等。二是网络犯罪打击和安全保护部门。即公安部及对应地方公安机关,主要负责网络犯罪预防、侦查和惩治,处置重大网络案件、治安事故和骚乱,指挥防范、打击网络恐怖活动,依法查处危害社会治安秩序的网络行为,保障网络安全、国家安全和社会治安等工作。三是网络宣传管理部门。即各级网络安全和信息化领导小组办公室,主要负责创新改进网络宣传,运用网络传播规律,弘扬主旋律,激发正能量,培育和践行社会主义核心价值观。四是网络各领域对应的主管部门。如文化部、新闻出版广电总局、卫计委、食品药品监督管理局、工商总局等部门及其对应地方机关,主要负责网络各个具体领域的规范和治理,网络行政执法机关多达近二十个。虽国家高度重视并作出相应制度安排,^①但实践中长期存在的行政执法部门林立、分段执法、分兵把口、相互掣肘有余、协调配合不足的困境尚未根本改变。网警、文化、工商、技术质量监督、广电新闻出版、食品药品监管、检疫、公共卫生等众多行政执法部门,仍然存在职权不清,权责模糊,相互推诿、揽功诿过的诸多弊病,尤其是在处理涉网重大、紧急、复杂且边界相对模糊的网络社会治理新情况、新问题,容易滋生网络社会治理“各自打扫门前雪、不顾他人瓦上霜”的现象。同时,网络社会的高速发展及其自身的专业性、技术性和复杂性特质,使得网络执法的难度加大,传统简单蛮管蛮控的方式与现代网络社会格格不入。网络社会发展变革、技术设备更新换代、网络安全防御能力和威慑能力提升等都对专业规范的网络执法方式和执法队伍建设提出崭新挑战。

第三,网络社会治理司法有着不少难题。互联网技术无边界、超地域、全球互联互通等特点,导致管辖界区的模糊,其直接带来的是网络社会治理司法管辖的“冲突”甚至“空白”。网络社会高速发展滋生网络智能犯罪、高技术犯罪,产生国内网络犯罪国际化、国际网络犯罪国内化的新趋势。智能型、技能型网络犯罪使得网络犯罪行为地、结果地变得越来越模糊,这种不确定性直接挑战传统的属地主义、属人主义、普遍管辖的管辖原则理论,尤其是网络跨国犯罪的迅猛增长,不仅挑战国内司法管辖,亦挑战国际司法管辖与合作,滋生网络社会治理国际司法合作调查协助取证难、收集固定证据难、提取转化运用证据难、司法裁判协助执行难、资产追缴返回难等棘手难题。网络违法犯罪呈现隐蔽性强、危害性大、犯罪主体年轻化、

① 为应对网络社会治理挑战,2014年2月27日成立了中央网络安全和信息化领导小组,明确“统一领导、统分结合、相对集中、职权确定、权责一致”的网络社会治理格局,要求建立国信办承担网络信息安全的指导、协调、督促工作;工信部主管互联网行业发展;公安部履行查处网络违法犯罪的治理格局,从制度设计层面重新作出安排。



犯罪对象广泛化、犯罪形式多样化、网络违法犯罪监管滞后等特点,为网络社会治理司法资源配置提出了新的挑战。^①当前,为适应网络打击犯罪的需要,在公安机关设置了网络执法机构,但检察机关、审判机关均未设置配备专门机构、专门力量,检察、审判机关是否有必要建立及如何承担网络社会治理方面的民事纠纷、行政诉讼及网络犯罪案件的司法职能都是新时期的网络司法难题。^②司法程序上,民事、行政、刑事实体法与相匹配的程序法对网络民事合同纠纷、侵权行为、行政违法、刑事犯罪等都未制定专门的法律或者专章规定,散见于各自的实体法或程序法之中。社会关系虚拟的网络社会与现实社会的法律模式和行为规范的假定条件、行为模式、法律后果等内容的差异,给执法司法人员对网络民事违法行为、行政违法行为、刑事犯罪行为的认定、裁断、处理、执行带来诸多困难,这些与我国加快推进网络社会治理法治体系建设,提高网络社会治理法治化水平的目标要求格格不入。^③

四、中国特色网络社会治理法治体系的构建

(一) 建立完备的网络社会治理法律规范体系

网络社会治理法律规范体系是以《宪法》关于网络社会治理原则规定为基础,以网络社会治理专门法律制度规范为主干,以与网络社会治理相关的行政法规、地方性法规、部门规章等规范性文件相协调相配套的治网、办网、用网、护网的法律体系。建立完备的网络社会治理法律规范体系的根本途径在于:

1. 更新立法理念。理念作为行动的指引,立法机关秉持公权与私权、实体正义与程序正义的平衡统一理念,以守卫网络空间安全与保障网络空间发展并重为立法出发点,是增进网络社会治理立法科学与民主,实现保障法治思维和法治方式推进网络社会治理法治化的行动指南。立法者须恪守现代法权意识和法治思维,通过赋

① 《新华网、猎律网联合发布〈2011—2015年度网络违法犯罪大数据报告〉》,2016年9月12日, http://news.xinhuanet.com/city/2016-09/12/c_129278082.htm,2016年11月3日。

② 值得注意的是,“检察、审判机关是否有必要设置互联网专门机构、配备专门力量”观点在实践中得到印证。2017年6月26日,中央全面深化改革领导小组第三十六次会议审议通过《关于设立杭州互联网法院的方案》。首家互联网法院的诞生既是网络社会高速发展在司法资源配置领域的体现,也是网络社会法律纠纷集中规模出现倒逼司法体制加速改革的必然结果。(参见《习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第三十六次会议》,2017年6月26日, http://news.xinhuanet.com/politics/2017-06/26/c_1121211704.htm,2017年7月11日)

③ 参见孙午生:《网络社会治理法治化研究》,北京:法律出版社,2014年,第132页。



权、确权、限权、护权,破解网络监管“部门林立、执法壁垒”与简单蛮管蛮控治网方式等难题,修复网络生态,根治网络乱象环生问题,保护个人网络空间合法权益,使法律赋予公民“被遗忘的权利”^①能够通过法定程序得到有效救济。

2. 科学制定法律规范。网络社会治理法律规范的制定,既关系到国家核心利益保护和国家网络空间主权安全守卫,又关系到公共利益、社会利益、个人利益之间的协调平衡。在一定意义上,这是对公民、法人、其他组织的个人权利、社会权利在某种程度上的限制。网络社会治理法律规范的制定须寻求国家职权适度让渡与个人私权有序保护的统一,坚持比较借鉴、创新转化和不断完善开展立法,通过网络社会治理立法成本效益前置评估、立法项目辩论、立法民主协商,拓宽公民、社会组织、基层网民群众实现网络立法的知情权、参与权、表达权、监督权的渠道,不断完善立法后评估机制,完善权力机关内部的制约协调机制、民意表达机制以及民意与立法的对接机制、实施效果评估机制等。^②立法机关可在推动《网络安全法》全面实施,有效维护网络空间主权、规范网络产品服务提供者和网络运营者安全义务履行行为、确保关键信息基础设施安全保护与重要数据跨境传输规则规范运行的同时,加快个人信息保护法、数据保护法的立法步伐,适时制定网络安全保护专门法如个人信息保护法、网络证据法,完善民事诉讼、行政诉讼、刑事诉讼中涉及网络诉讼的程序规定,考虑细化实化网络程序和实体法规,甚至可设专章、专篇或单独立法,又要关注网络行业规范、自治规则、自律公约等行业规程,使之相互协调并有序衔接,形成网络空间治理的“门类齐备,结构合理,功能健全,保障有力”的完备网络社会治理法律制度体系。同时,应缜密规范立法,为相关下位法规制定预留接口,使数据保护法、个人信息保护法、“被遗忘的权利”等网络治理规则在整体上形成严密的逻辑结构体系。

(二) 建立高效的网络社会治理法治实施体系

1. 多元主体保障实施。网络社会治理法治的实施是指各种网络社会治理法律规范被各治理主体实施贯彻、有效执行的活动及其过程。作为规范网络社会治理活动有序开展的网络社会治理法律制度,其实施通常需要“压制性资源”和“引导性资源”两种资源的整合运用,使强制性功能与引导性功能有机结合。这种“压制”和“引导”直接体现在网络社会治理法治实施的主体上。网络社会治理法律规范“硬法”属性与网络社会治理公约、民约“软法”属性的彰显,网络社会治理自律性和他律性的功效互动释放,网络社会治理法律的实施,既要求网络社会治理主体积极

① 被遗忘权是用于个人信息数据被不当获取或使用时的救济制度。(参见万方:《终将被遗忘的权利——我国引入被遗忘权的思考》,《法学评论》2016年第6期)

② 江必新:《怎样建设中国特色社会主义法治体系》,《光明日报》2014年11月1日,第1版。



主动地行使权利（力）和履行义务（责任），遵守网络社会治理法律规范；也要求国家行政机关、司法机关以及经授权或委托的组织及其公职人员，须毫不例外地依照法定职权和程序，执行网络社会治理法律规范；还要求网络社会治理主体根据法定职权和法定程序，运用网络社会治理法律规范，处理网络社会治理事务、自治事务及个人事务的活动。这都决定了应将网络社会治理主体界定为与《宪法》、《民法通则》、《侵权责任法》、《合同法》等相一致，包括国家网信部门，相关行业主管部门及各级政府、行政执法、司法机关，公民（网民）、法人（网络组织）及其他组织等。进而建立政府主导、社会协同、公众（网民）参与的网络社会多元主体治理格局，形成国家专门机关实施与自治组织、社会团体、行业组织、网络组织和网民的自治自律、合作共治，使网络社会治理主体多元性与共治性有机结合，保障网络社会治理法治实施。

2. 重点规范网络服务提供者行为。网络社会治理法治高效实施的根本在于法律规范本身具有可实施性、可接受性以及法律规范自我实现的动力与能力，其重要途径在于网络社会治理的全面调整与重点规范相结合。在网络“信源→信道→信宿”结构关系中，网络服务提供者对应的是“信道”这一网络信息传输中具有中枢地位和作用的信息桥梁和通道。通过规范网络服务提供者这一网络信息传输的中枢，即重点规范网络连线服务商、网络平台服务商和网络内容服务商等网络服务提供者，治理主体充分利用技术优势和监管优势，有序分步对设备、连线服务链接、搜索引擎、提供存储空间规避技术网络服务等网络服务提供者提供的服务和行为进行有效规制。网络服务提供者违反现行法律、行政法规规定的网络信息安全管理义务，经监管部门通知采取改正措施而拒绝执行且触犯刑法的行为，依法追究其刑事责任，保障网络服务提供者严格依照网络社会治理法律规范提供服务，推动网络社会治理法律的有效实施。

3. 强调行业自治。遵守宪法、法律和法规关于网络社会治理的相关规定，弘扬社会道德风尚，净化网络空间，建设有序的健康网络社会环境是网络社会中企事业单位、个人的社会责任。各网络组织、网络行业协会、网络非营利社会团体既有组织制定网络行约行规，维护行业整体利益，实现网络行业自律的利益驱使，也有自身优势。因此，应充分利用网络自治组织、网络行业协会自身优势，强调网络自治组织、网络行业协会依法自治，将互联网行业应当遵守的商业道德、相关技术标准等基本规则转化为具有一定约束力的行业自律规则，推动网络服务行业依法自治，实现自我管理、自我教育和自我服务。鼓励网络自治组织参与网络社会治理的监管和消费维权各个领域、各个环节，通过行业自律、社会协同的方式，规范网络交易行为，有效推动和提高网络社会治理法治化水平。同时，要充分发挥舆论和公众的监督作用，调动包括行业自治在内的一切积极因素，宣传贯彻国家网络社会治理政策、法律法规，提高互联网的应用水平和服务质量，提高网络社会实现自我管理、



自我规范和自我净化水平。

当然，高效的网络社会治理法治实施体系的建立是一个系统工程，优化网络治理法治人文环境，推动国际执法合作，构建高效的国际执法体制和机制，充分利用国际刑警组织、国与国之间的双边与多边合作机制，加强对跨国（境）网络犯罪活动的打击力度等也是建立高效网络社会治理法治实施体系的重要举措。

（三）建立严密的网络社会治理法治监督体系

1. 强化法律监督。监督是权力正确运行的根本保证，网络社会发展秩序与安全的维护，公民、法人和其他组织网络空间合法权益保障等，既需要法律来规范调整，还需要法律的监督。职权机关依照法定职责和程序，对网络社会治理活动或某一环节、过程进行监视、督促和管理，其主体是国家机关、社会组织、公民，其核心是对网络社会治理活动的合法性进行监察和督促。首先，强化对人大立法机关制定网络社会治理规范性法律文件的合法性监督。建立依法提请全国人大及其常委会撤销和纠正违宪的网络社会治理规范性法律文件制度。其次，强化对行政执法活动的合法性监督。强化人大对网络社会治理行政执法活动的监督，定期开展网络社会治理领域的执法检查。^①再次，强化对司法活动的监督。建立健全人大及其常委会对司法机关有关网络案件裁断活动的监督。

2. 提升监督能力。法律制度禀赋与治理资源独占所形成的政府主导地位和作用能否充分发挥，监督优势能否显示，基本途径在于提升网络社会治理公权力机关公职人员的法律素养和监督能力。因此，增强法律素养、培养法治意识、强化网络法治思维是提高监督主体依法监督网络社会治理活动能力和水平的关键。同时，提升网络技能和运用技术监督的能力是保障网络社会治理公权力机关正确行使权力的重要内容。通过协调核心技术与普通技术认证体系，明确网络安全技术准入标准，科学评价网络产品和技术的安全性能，统筹国内网络安全技术标准认证与国际网络安全技术标准认证衔接，构建科学化、标准化、规范化的网络安全技术认证监督体系，增强我国网络社会治理公权力机关的业务能力和法治素养。

3. 突出政府监督。政府监督是严密网络社会治理法治监督体系制度建立的主导，这也与“党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障”的社会治理体系吻合匹配。^②网络社会严密法治监督体系的建立，须科学配置政府网络社会治理监督权力，明确设定政府监督权力运行的法律范围、要件和程序，规范网络社会治理监督权有序运行，使政府网络社会治理决策权、执行权与监督权相互制约又相

① 参见徐汉明、张新平：《社会治理法治建设指标体系的设计、内容及其评估》，《法学杂志》2016年第6期。

② 江必新、邵长茂：《社会治理新模式与行政法的第三形态》，《法学研究》2010年第6期。



互协调,防止权力滥用。同时,有效运用党内监督、人大监督、民主监督、司法监督、审计监督、社会监督和舆论监督手段,使网络社会治理各项监督协调配合,既形成合力又互相制衡,防止权力的不当行使和违法乱用。^①

(四) 建立有力的网络社会治理法治保障体系

1. 优化技术保障。网络社会赖以存在的技术注定应该是用于满足各类社会需要的工具,也即:“技术归化”是网络社会治理的必然要求和核心内容。网络社会治理法治保障体系同样建立在技术保障的基础之上,充分运用现有技术,又要放眼长远,占领未来网络社会的技术高地;普及应用防火墙、数据加密、过滤、身份认证、数字签名等技术,全面构筑我国网络安全保护屏障;组建国家互联网关键技术攻关重点实验室,引进全球高端人才,加大对网络信息核心技术的研发攻关力度,形成引领世界且具有自主知识产权的计算机芯片、操作系统、安全防控等关键核心技术体系,打破以美国等现代发达国家为绝对主导的全球互联网发展格局,占领未来网络社会发展的技术高地和战略高地;鼓励企业、科研机构参与网络技术创新与研发;加大对企业的政策、资金支持和投入力度,通过贷款贴息、税收优惠减免、进出口退税等措施,鼓励互联网企业、网络服务提供商革新技术,参与国际网络交流合作。

2. 强化人才支持。人才队伍是建立有力网络社会治理法治保障体系的根本。网络世界的竞争,归根结底是人才的竞争。治理网络社会,“建设网络强国,没有一支优秀的人才队伍,没有人才创造力迸发、活力涌流,是难以成功的”。^② 因此,应大力培养网信技术人才与网络法治人才,重视网信技术人才与网络法治人才培养师资队伍和教材体系建设,建设一流网络社会治理法学学科与网络空间安全学院。完善网络社会治理执法职业准入制度,从源头上把好专门队伍的素质关。健全网络社会治理公职人员职前培训制度,加大高等院所、科研机构与网络社会治理立法、执法、司法队伍的人才互动交流力度,形成协同创新良性互动的人才培养与合作机制。推进网络社会治理法治专门队伍正规化、专业化、职业化建设,提高职业素养和专业水平。建立“网络社会治理法学”专业人才培养机制,构建中国特色社会主义网络社会治理法学学科的理论体系、教材体系、课程体系。着力打造政治立场坚定、敢于担当、忠诚干净、技术精湛、理论功底深厚,善于运用法治思维和法治方式“治网、办网、用网、护网”的网络治理法治领导人才和专门人才队伍。

① 参见鹿心社:《全面推进行政权力运行法治化》,《人民日报》2015年3月24日,第7版。

② 参见习近平:《在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话》(2016年4月19日),《人民日报》2016年4月26日,第2版。

结 论

我国已经进入网络社会，但其治理问题，尤其是运用法治思维和法治方式对其进行治理，尚需及时跟进。传统非基于技术归化而来的治理模式自身设计存在一定缺陷，无法及时有效应对网络社会中出现的网络欺诈、网络谣言、网络赌博、网络贩毒、网络色情等各种问题。因此，新的基于技术归化而来的法治治理理论、制度与实践相结合的网络社会治理模型与范式亟待出现，即网络社会治理的法治模式。网络社会治理法治模式是将网络社会治理活动全过程纳入法治轨道运行的治理实践、理论与制度。没有网络社会治理法治建设实践探索，网络社会法治治理理论形成发展和制度创新完善便失去了基础；没有网络社会法治治理理论的指引，网络社会法治体系制度创新和道路拓展便失去了支撑；没有网络社会法治体系及制度构建，网络社会治理法治建设道路拓展和理论创新便失去了保障。没有网络社会法治治理实践、理论与制度的有机结合，就没有网络空间“平等尊重、创新发展、开放共享、安全有序”治理目标的实现。

法治作为规则之治，是现代文明国家治理的最佳选择和基本形式。网络社会治理法治模式的提出，既是已有现代文明成果的有益汲取，又是网络社会技术归化独特要求的体现。基于网络社会治理法治模式的理论分析和我国网络社会治理法治建设的道路总结，可以为中国特色网络社会治理法治制度体系构建提供智力支撑，进而提高网络社会治理法治化水平，建设网络强国，推进包括网络社会在内的国家治理体系和治理能力现代化，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

〔责任编辑：刘 鹏〕